

0008793-29.2017.8.26.0099

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008793-29.2017.8.26.0099

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1386/2017 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 58/17 - Delegacia Seccional Bragança Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO CARDOSO DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

TIAGO CARDOSO DA SILVA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/2006, além do artigo 329, § 1º, do Código Penal, porque no dia 20 de março de 2017, na rua Duque de Caxias, 93, Apto 02, Vila

Aparecida nesta cidade e Comarca, agindo em concurso com Eric Guilherme de Macedo, Paulo Ricardo Franco Mourão, Anna Paulla Brhayen Silva Oliveira, Caroline Silveira Beltrame e Daiane Franco Mourão (processo desmembrado), guardava, para venda, fornecimento ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, 18 porções de maconha, pesando aproximadamente 2.050 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, TIAGO CARDOSO DA SILVA, associou-se com os demais denunciados (processo desmembrado), para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que na mesma ocasião, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente, não se realizando o ato em razão da resistência oferecida.

Recebida a denúncia aos 06 de novembro de 2017 (fl. 608), o acusado não foi localizado para citação pessoal, razão pela qual realizou sua citação por edital. Como não apresentou resposta, nem constituiu patrono, determinou-se a suspensão do procedimento nos termos do artigo 366, do CPP (fls. 585 e 608/609).

Localizado, promoveu-se sua citação pessoal aos 18 de novembro de 2021 (fl. 695), seguida de apresentação de sua resposta à acusação (fls. 699/700).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 701), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 745).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 746/755).

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade da prova obtida por meio ilícito (invasão de domicílio). No mérito, postulou a absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos, postulando, subsidiariamente, pela desclassificação do tráfico para o crime previsto no artigo 28, da lei especial (fls. 758/777).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não prosperam as alegações da defesa nesta seara.

Não há que se falar na nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do acusado em razão da ausência de autorização judicial para a execução da medida.

Primeiro porque razoável quantidade de drogas foi devidamente apreendida, materializando-se o ato mediante lavratura em termo próprio, escriturado pelos policiais civis durante a confecção do auto de prisão em flagrante, conforme se depreende pelo documento de fls. 188/192, assinado por duas testemunhas.

Ao depois, não se sustenta a alegação de que inexistia autorização judicial para o ato que teria violado o domicílio do acusado, haja vista que a prisão em flagrante dos coacusados (processo desmembrado), diante das circunstâncias em que ocorreu, com a apreensão de drogas, legitimou a atuação policial.

Saliente-se que, mesmo se assim não fosse, dada a natureza permanente do crime imputado, cuja consumação prolonga-se no tempo, a autorização judicial era prescindível, pois indubitavelmente caracterizada situação de flagrância.

Destarte, sem razão o argumento defensivo no sentido de que ocorreu nulidade na apreensão do entorpecente.

Nesse sentido a Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS, RESISTÊNCIA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Preliminar de ilicitude da prova obtida por invasão de domicílio – Inocorrência – Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo que são crimes permanentes, de consumação prolongada no tempo – Presença da situação flagrancial que prescinde de autorização judicial – MÉRITO – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Validade das palavras dos agentes públicos – Luís Felipe que tinha em depósito

grande quantidade de cocaína com destinação a terceiros – Apelante que ainda resistiu à prisão – Corréu Stinguel que possuía arma de fogo com numeração suprimida – Crime de mera conduta, que independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo à sociedade, bem como de perigo abstrato, ante a probabilidade de ocorrência de dano pelo uso inadequado da arma, presumido pelo tipo penal – Bens jurídicos tutelados que são a segurança pública e a paz social – Prescindibilidade de laudo pericial na arma para a configuração do delito – Condenações irreparáveis – Penas e regime criteriosamente aplicados – Sentença mantida – Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 00012989820178260594 SP 0001298-98.2017.8.26.0594, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 28/05/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/06/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 632423 SP 2020/0330802-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).

No mérito, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está plenamente comprovada.

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 387/390) descreveu e concluiu que a substância analisada é maconha, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos a autoria também se evidenciou, muito embora o acusado tenha negado a prática da infração em seu interrogatório.

Tiago argumentou que apenas possuía no interior de sua residência aproximadamente dez gramas de maconha, destinadas ao seu consumo pessoal.

Ele sequer justificou a existência do restante da droga apreendida em sua casa, aproximadamente dois quilos de maconha, em que pese não haver dúvidas sobre a apreensão do entorpecente pelos policiais. Não é crível que policiais inventem fatos ou “enxertem” a droga em desfavor de acusados, em especial quando sequer vestígio a respeito existe nos autos.

De igual forma, não explicou com segurança o motivo de ter fugido dos policiais no instante em que eles o abordaram.

No mais, ele se escusou da imputação por meio de simples negatória geral, sem indicar por quais motivos poderiam os policiais querer lhe imputar injustificadamente crime de tamanha gravidade.

Se não bastasse a força de convencimento nesses elementos, corroboram a certeza da autoria os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução.

Senão vejamos.

OPM Claudio relatou que havia denúncia de populares indicando o tráfico de drogas pelo morador de um sobrado situado na Vila Aparecida. Contou que no dia dos fatos, novamente recebeu informação sobre a prática criminosa, mais precisamente de que o ocupante de um veículo Ônix teria chegado ao local com as drogas. Diante disso realizou patrulhamento pelo local, quando avistou referido veículo estacionado em frente à residência.

Acrescentou que, na companhia de seu colega de farda PM Jonas, dirigiu-se até a casa e bateu na porta. Declarou que foi atendido pelo acusado e por Eric (processo desmembrado). Esclareceu que enquanto ficou na porta escoltando os coacusados, o PM Jonas adentrou no local, uma vez que ambos sentiram um forte cheiro de maconha vindo do interior do imóvel.

Narrou que, aproveitando-se do fato de terem ficado somente em sua presença, Tiago e Eric entraram em luta corporal consigo e o derrubaram ao solo, fugindo em seguida. Mencionou que, não obstante a perseguição, o acusado não foi localizado naquele dia. Porém, após realizada vistoria em sua residência, ali foram encontradas dezoito porções de maconha, pesando aproximadamente dois quilos. Salientou, também, que no imóvel foi apreendida uma balança de precisão, além de diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para o embalamento de drogas. Pontuou que na casa do acusado havia outras pessoas (coacusados - processo desmembrado) que foram encaminhadas à Delegacia de Polícia e autuadas em flagrante delito. Finalizou dizendo que após a prisão dos coacusados, Tiago publicou no facebook que era ele o dono daquela droga, assim como admitiu ser traficante, numa tentativa de isentar os demais.

Por sua vez, o PM Jonas disse que alguns moradores da Vila Aparecida noticiaram a prática do tráfico de drogas pelo acusado, conhecido como Coreano. Naquela ocasião, nova denúncia anônima informou que um veículo Ônix, cor prata, entregaria drogas no local. Ciente desta informação, rumou até a casa do acusado, ocasião em que observou um veículo com idêntica característica estacionado na frente do imóvel.

Posteriormente, foi até a porta de entrada do imóvel, bateu na porta e foi atendido pelo acusado e por Eric. No entanto, sentiu cheiro de maconha exalando do interior do imóvel, razão pela qual, enquanto seu colega de farda permaneceu com os dois acusados na parte térrea, subiu as escadas do sobrado e se deparou com mais quatro indivíduos (coacusados - processo desmembrado) na sala do imóvel, todos manuseando drogas. Declarou que durante a diligência Tiago conseguiu fugir, motivo pelo qual não foi preso naquele dia.

O PM Junio aduziu que foi acionado para prestar auxílio aos demais policiais. Disse que no instante em que chegava ao local visualizou dois indivíduos saindo do imóvel e correndo na via pública. Frisou que somente conseguiu capturar um deles (Eric). Por fim, ratificou o encontro de drogas dentro da casa do acusado, além de uma balança de precisão.

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão do acusado tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade do agente. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frisa-se também que os agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada desde a chegada ao local e a fuga do agente, assim como a localização da droga, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE -RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhai colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e

uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014) Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, em sua forma bruta, pronta para ser fracionada, os materiais normalmente utilizados para o embalo e pesagem de entorpecente, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

A delação também deve ser levada em consideração porque jamais os policiais encontrariam a droga e investigariam a situação de traficância se não possuíssem informação confiável.

As denúncias anônimas são importantes fontes de informações para a polícia e, quando são confirmadas as delações com elementos concretos nos autos, merecem guarda para sustentar a acusação de tráfico de entorpecentes, pois não se pode esperar que a pessoa delatora de tão grave delito assuma sem temor sua identidade, ante a usual represália emanada dos inúmeros traficantes de drogas que mutuamente se ajudam.

Saliente-se, que no procedimento sob nº 228-96.2017, que tratou dos mesmos fatos e tramitou contra os demais coacusados (Eric, Paulo, Anna, Caroline e Daiane - processo desmembrado), a defesa de Daiane colacionou às fls. 733/734 uma suposta "declaração" de Tiago, realizada em sua rede social, admitindo ser traficante e proprietário das drogas apreendidas em sua casa, além de isentá-los de qualquer envolvimento nos fatos.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenha o agente efetuado a venda. Basta que a possua ou tenha em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitación do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor a venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afim, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada

a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, verbi gratia, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

Ora, a conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente à figura "guardar ", prevista no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico. Inadmissível o pedido de desclassificação do delito imputado quando ausente a prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa e não da acusação o ônus da prova cabal e irrefutável da alegação de ser usuário e dependente, mesmo porque a condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário de droga.

Sobre a matéria:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para a entrega e consumo de terceiros, drogas, consistentes em 21 (vinte e uma) porções de "Cannabis Sativa L.", popularmente conhecida como maconha e possuía e mantinha sob sua guarda 12 (doze) munições, calibre 22, uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida, e as circunstâncias de sua apreensão, afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. (TJ-SP - APL: 00008425720168260474 SP 0000842-57.2016.8.26.0474, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019).

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida desclassificação para uso próprio, ou, subsidiariamente, afastamento da reincidência, mitigação da pena, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional para o início de cumprimento de pena e detração penal. Descabimento. 1. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado colocar algo em sua boca em atitude suspeita, justificando sua abordagem. Realizada busca pessoal, Renan cuspiu do interior de sua boca oito pedras de crack envoltas em papel alumínio. Ato contínuo, dando continuidade à busca, os milicianos encontraram em poder do acusado, mais especificamente no interior de suas vestes íntimas, trinta e quatro porções de maconha, todas acondicionadas separadamente em sacos plásticos. Ainda, no interior dos bolsos da bermuda que o denunciado vestia, os policiais apreenderam um celular Motorola e a quantia de R\$ 68,00 em espécie. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e natureza da droga apreendida, afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. 2. Dosimetria. A) Decisão bem fundamentada nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. B) Acusado reincidente específico que justifica o aumento adequado e proporcional aplicado pelo duto sentenciante, na segunda etapa da dosimetria da pena. C) Aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Acusado reincidente, sendo suficiente a reincidência para a negativa da diminuição. Presença de elementos que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício. 3. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente - Artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei nº 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma,

impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5º, XLIII, da Constituição Federal e 33, § 3º, do Código Penal. 4. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), surge inaplicável a detração, para tanto, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, b, LEP). Negado provimento. (TJ-SP - APR: 00005459420188260566 SP 0000545-94.2018.8.26.0566, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 23/05/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2019).

Assim sendo, os argumentos defensivos ficam sem guarida nenhuma nos autos. Não obstante os argumentos já expendidos em relação ao crime de tráfico, não deve prosperar a imputação de associação para tal finalidade.

Isto porque o acusado nada admitiu neste particular. Nenhum vestígio existe a respeito de uma eventual associação duradoura e estável entre ele e os demais acusados. Os policiais nada relataram sobre a associação imputada.

O crime de associação se distingue do concurso eventual de pessoas que exige um acordo de vontades ocasional e efêmero para a perpetração de determinado crime; a associação pressupõe ajuste permanente ou estável para a perpetração de vários crimes de tráfico de entorpecentes (mínimo dois).

A propósito, dispõe o artigo 35: Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1.º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Com efeito, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a) reiteração ou não "jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33 e 34 da lei nº 11.343/2006, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, não havendo necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição.

Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho:

"Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..."(GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei n.º 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei 6368/76 - 12.ª ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

Portanto, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris* em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

Na espécie, repise-se, inexistem elementos sólidos a embasar o édito condenatório, não havendo como reconhecer, *in casu*, o delito de associação.

Restando, pois, sem comprovação o animus associativo mais ou menos estável ou permanente, não há que se falar em associação para o tráfico, pois, para a sua caracterização é indispensável à associação de duas ou mais pessoas; acordo dos parceiros; vínculo associativo; e a finalidade de traficar tóxicos, formando uma verdadeira *societas sceleris* para essa finalidade.

Não se vislumbrou a ocorrência de outros crimes de tráfico, como ainda, uma estabilidade na relação entre todos os acusados, ainda mais se levarmos em conta a absolvição dos demais.

Por fim, quanto à resistência, ela também não ficou devidamente demonstrada.

Os fatos envolvendo a resistência denunciada operaram sem uma concreta violência ou ameaça eficaz do acusado.

A vítima PM Claudio disse que Tiago não lhe agrediu, apenas o derrubou ao solo enquanto tentava fugir do local.

Portanto, está nebulosa a situação, ou seja, não há certeza se o acusado reagiu à ação dos policiais que tentaram detê-lo, ou se tomou a atitude ativa de agredir os agentes.

A conduta encartada como afrontosa a lei penal é a de oferecer oposição ao ato legal de execução, com a demonstração de força por via de violência ou ameaça. O foco da conduta ilícita está na demonstração do agente com a insatisfação na execução do ato e também que esta provenha de forma comissiva, dirigida diretamente contra o agente público encarregado do cumprimento do ato. A ação positiva deve revelar uma violência ou ameaça, pois caso revele somente uma forma omissiva, com uma resistência pacífica, sem as elementares agressivas, descaracteriza a infração. Assim, nos remetemos à lição de Julio Fabbrini Mirabete, cuja lição é no sentido de que: "A oposição à prática do ato legal deve ser atuante e positiva, não a configurando a resistência passiva, a passividade do agente, a atitude que, embora possa ser tendente a impedir o ato legal, não se configura em violência ou ameaça (RT 509/343, 601/332, 356/307, JTACrSP 74/261; RF 264/344).

A eventual resistência do acusado foi para reagir ao ato da sua prisão por tráfico de drogas, foi uma reação natural, sem os contornos do tipo legal.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes criminais não recomendam exacerbação. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

No entanto, levando em consideração as circunstâncias do crime, a par da quantidade da droga apreendida, em obediência ao teor do artigo 42, da Lei 11.343/2006, vemos que as penas-base comportam acréscimo por conta deste fator.

Presente a circunstância judicial acima exposta, que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa no patamar mínimo legal.

Na segunda etapa, certificada a reincidência do agente a fls. 741/742, suas penas serão elevadas em 1/6, não havendo outras agravantes ou atenuantes a considerar (6 anos + 1/6 = 7 anos/600 dias + 1/6 = 700 dias-multa).

Na etapa derradeira, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

O acusado é reincidente, razão pela qual não se amolda na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

O crime de tráfico foi equiparado, legalmente, aos hediondos, motivo pelo qual, em relação a ele, o condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, mesmo porque a reincidência impede a substituição. Também compartilho do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias envolvidas, de modo que a concessão de regime menos gravoso ou mesmo de qualquer outro benefício, como a substituição da pena ou mesmo do sursis, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou mesmo reprovação do da prática delitativa, gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade.

Por conta dos mesmos fundamentos o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena

por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente a droga provoca.

O sentenciado poderá apelar em liberdade porque respondeu ao procedimento nesta condição e o Juízo não vislumbra como presentes os requisitos da prisão cautelar.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

A) ABSOLVER TIAGO CARDOSO DA SILVA, qualificado nos autos, das imputações do artigo 35, da Lei de Drogas e do artigo 329, § 1º, do Código Penal, que lhe foram feitas, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

B) CONDENAR TIAGO CARDOSO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Com o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote-se o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 30 de maio de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA